

1502754-93.2020.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... fé pública; o réu está envolvido com o tráfico de drogas desde longa data; o réu ostenta maus antecedentes; há agravante do crime cometido durante período de pandemia e há relação direta com o crime de tráfico de drogas e cria ambiente fértil para o delito; não incide a diminuição do art. 33, § 4º, pois o réu já condenado por antecedentes infracionais e como imputável por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502754-93.2020.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502754-93.2020.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2128300/2020 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 8788813 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 1974/20/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 1975/20/506 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2128300 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Antônio Carlos dos Santos Filho, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Narrou que no dia 22 de maio de 2020, por volta das 17h00min., na Rua Geraldo Brisola, nº 28, Vila São Benedito, nesta cidade e Comarca, Antônio trazia consigo 05 porções de maconha, além de guardar outras 18 porções em sua residência, totalizando 102,730g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que policiais

receberam notícias anônimas a respeito da venda de drogas realizada pelo acusado, avistaram-no em via pública, abordaram e localizaram com ele 05 porções de maconha; em busca domiciliar autorizada pela mãe do acusado localizaram mais 18 porções da mesma droga, escondidas no muro do fundo do imóvel.

Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fl. 176).

A denúncia foi recebida em 17/12/2021 (fl.177).

Foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu (fls.201/202).

Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu, sob os argumentos de que: os policiais ouvidos depuseram de forma segura e harmônica, receberam denúncia de que Antônio estava traficando, acompanhada de uma fotografia (fl.19); encontraram com ele porções de maconha, na casa do réu mais porções com embalagens idênticas; a genitora disse ter autorizado o ingresso e contou que os policiais voltaram dos fundos da casa trazendo os entorpecentes apreendidos; os policiais acharam essa droga no interior do muro que guarnece a casa do acusado e que a mãe dele confirmou a traficância pelo filho; a genitora comprovou, dentro do possível, que o filho estava envolvido com a traficância; ela comprovou o relato dela na fase policial; a versão de que foi vítima de armação policial e não tinha a droga quando da abordagem não convence por não ter sido comprovada e significaria colocar em dúvida a palavra de agentes que gozam de fé pública; o réu está envolvido com o tráfico de drogas desde longa data; o réu ostenta Maus antecedentes; há agravante do crime cometido durante período de pandemia e há relação direta com o crime de tráfico de drogas e cria ambiente fértil para o delito; não incide a diminuição do art. 33, § 4º, pois o réu já condenado por antecedentes infracionais e como imputável por tráfico; o regime prisional deve ser fechado, sem substituição de pena.

A douta Defesa pediu a absolvição do réu. Em preliminar alegou que o processo é nulo, pois teve origem com denúncia anônima apontando o réu como traficante; o fato de estar andando na região da denúncia não é prova suficiente, já que confessou ser usuário. No mérito, sustentou que: não há prova do tráfico; a abordagem foi premeditada e não houve revista pessoal, tanto que o réu entregou na delegacia dois isqueiros que estavam consigo; não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga; não basta a apreensão do entorpecente para a caracterização do tráfico; o acusado é usuário e não comerciante. Pediu a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls.204/214).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A douta Defesa sustentou a nulidade do processo pelos policiais militares terem recebido denúncia anônima de que o réu estaria traficando e a fotografia dele. Respeitada a jurisprudência no sentido contrário que defende a imprestabilidade da denúncia anônima, esta é comumente utilizada pela Polícia no combate à criminalidade e não pode ser desprezada como elemento indiciário apto a legitimar as operações executadas quando no desempenho de seus trabalhos.

Com efeito, os policiais militares prestam serviço de policiamento ostensivo e não há qualquer irregularidade em abordar e revistar pessoas suspeitas na rua quando tiver fundada suspeita de que a pessoa está escondendo armas de fogo, drogas ou objetos que serão usados para a prática de crimes, sendo que a busca deve ser realizada por policial do mesmo sexo que o cidadão abordado (art. 240, § 2º, Código de Processo Penal).

No caso concreto restou devidamente justificada a fundada suspeita. Além da denúncia recebida, Antônio Carlos já era conhecido dos meios policiais. Extrai-se da certidão de antecedentes de fls.194/196 que o réu ostenta condenação anterior definitiva por tráfico de drogas. É de conhecimento deste Juízo que o réu possui várias passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, tanto que a genitora falou no depoimento que ele trafica desde os 13 anos.

Enfim, a denúncia anônima é suficiente para justificar diligências da polícia, dentre elas a busca pessoal. Portanto, afasto a preliminar de nulidade do processo.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.22); boletim de ocorrência (fls.04/12); auto de exibição e apreensão (fl.13); laudo de constatação e laudo de exame químico de entorpecente (fl.17). Extraí-se do laudo pericial que foram periciados fragmentos vegetais, com resultado positivo para Tetrahidrocanabinol - THC. A autoria é certa e atribuída ao acusado, conforme prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório Antônio Carlos afirmou que estava na casa de sua ex-mulher, mãe do filho, com ela, tinham brigado e foi se reconciliar. Relatou que policiais lhe enquadraram e a sogra estava no portão, não acharam droga no seu bolso e colocaram na viatura. Mencionou que eles foram na sua casa, pediram à mãe para entrar e ela deixou, voltaram de lá com uma sacola na mão. Declarou que eles lhe prenderam por tráfico, mas não lhe revistaram. Negou ser verdade que tinha cinco porções de maconha no bolso, tinha apenas 2 isqueiros que apresentou ao delegado na Delegacia. Negou ser suas as 18 porções que estavam nos fundos da casa. Salientou que antes mexia com drogas, mas não estava mais nessa vida. Contou que o policial Negrini e o Guilherme lhe perseguem e falaram que iam acabar com a vida do depoente, que ia apodrecer na cadeia. Negou que a droga seja de sua genitora. Disse que já correu da polícia, eles lhe bateram e falaram que o que era dele estava marcado. Admitiu que já foi condenado por tráfico de drogas. Falou que fazia bicos, trabalhou com gesso e como servente, ganhava R\$ 350 por quinzena.

A testemunha Guilherme afirmou que recebeu informação de que no bairro Colina o réu Antônio Carlos estava traficando drogas, já tinha informações de que ele traficava na região. Relatou que patrulharam o bairro, ele estava com blusa de frio, encontraram 5 porções de maconha. Mencionou que ele disse que a droga era para uso dele. Declarou que perguntado se tinha mais droga ele respondeu que não, a mãe dele autorizou o ingresso e falou saber que o filho traficava. Salientou que nos fundos da casa, num muro, encontrou mais 18 porções de maconha, as quais o réu negou ser dele. Negou ter dinheiro com ele. Negou ter pessoas junto com ele no momento da abordagem, ele estava numa rua paralela da casa dele. Esclareceu que a denúncia não falou especificamente o local, só falou que ele traficava no bairro Colina.

Tais informações foram confirmadas pela testemunha Negrini. Confirmou que a genitora dele lhes disse saber que o filho estava traficando drogas e "demorou para ele ser preso". Acrescentou que no muro dos fundos da casa do réu achou 18 porções de maconha iguais às que ele trazia na rua. Disse que o réu negou ser dele aquelas drogas que estavam na casa. Negou ter localizado outro objeto que indicasse ele estar traficando. Falou que dias depois dos fatos o réu foi surpreendido em outra situação vendendo maconha.

A informante Patrícia afirmou que é genitora do réu. Relatou que agora o filho não está mais traficando, quer trabalhar e dar um rumo para vida dele. Mencionou que policiais falaram que acharam mais drogas com ele, autorizou o ingresso na residência, policiais vieram dos fundos do muro e falaram que acharam lá. Disse que o filho estava dando trabalho na época. Contou que o filho sabe o que fez, não precisa ficar falando. Ressaltou que o filho não trabalhava na época, agora que está trabalhando. Declarou que na época dos fatos morava na casa a depoente, a filha de 16 anos e marido, os quais não usam drogas. Falou que nem tinha dinheiro para dar ao réu na época, ele não conseguia dinheiro, a depoente que comprava chinelo e roupas, essa vida é só ilusão e agora ele acordou para vida. Informou que teve que tirar o filho de casa e agora ele falou que quer arrumar um serviço, para ele voltar precisa ver que ele vai ser diferente. Contou que o tráfico de drogas adotou seu filho com 13 anos de idade. Confirmou que pediu uma protetiva contra o filho porque ele teve época de rebeldia, foi mais para tirar ele de casa. Negou saber se os policiais têm motivos para prejudicar o réu, já não tem mais contato com filho.

Pois bem. Ressalto que o tráfico de entorpecentes se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva

tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Segundo a prova testemunhal, os policiais receberam denúncia anônima com foto do acusado, alegando que ele estava traficando drogas no bairro Colina. Realizaram diligências pelo local e o encontraram na via pública. Durante a abordagem encontraram cinco porções de maconha no bolso de sua blusa, as quais disse que seriam para consumo próprio.

Indagado sobre ter mais drogas guardadas o réu negou, porém os policiais se deslocaram até sua casa, sua genitora autorizou o ingresso dos policiais e lhes disse que já sabia da prática de tráfico pelo filho. No muro dos fundos da casa do réu foram apreendidas mais 18 porções de maconha, embaladas de forma idêntica àquelas que o réu portava.

Malgrado o réu negue a revista e estar com as porções de drogas, a versão dele restou isolada nos autos. Ele disse que estava com sua ex-mulher e sogra, mas não trouxe nenhuma testemunha em Juízo para confirmar que durante a abordagem não trazia nada de ilícito. A versão dele foi desmentida pelos depoimentos dos policiais, que, demonstrando coerência e isenção de ânimos, descreveram o ocorrido, merecendo, assim, a fé deste juízo.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas que teriam ensejado a prisão do réu.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais incumbidos do dever da repressão penal (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).

Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais ou guardas civis. Não há elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o réu e não se pode desmerecer a fala só por pertencerem aos quadros da Polícia. Foram submetidos ao contraditório como qualquer testemunha. Seria contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção da criminalidade e lhes negar esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta de suas atividades.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre a validade dos depoimentos dos policiais: "(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª ed., São Paulo: RT, 2007, p.323).

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres

Britto j.05.09.06 DJU 16.02.07, destaquei).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p.39.846, destaquei).

Na mesma linha é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. [...]. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS OFENDIDOS. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA. [...] 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada. (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011, destaquei).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. [...]" (STJ HC 149.540/SP 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.2011 DJU 04.05.2011, destaquei).

"O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos". (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013, destaquei).

Em verdade, o réu buscou se exculpar do crime, chegando a afirmar que os policiais que atenderam a ocorrência o perseguiram. Todavia, não trouxe elementos concretos de que pudesse existir qualquer animosidade entre eles. Portanto não vislumbro fundadas razões que abalem a fé pública dos agentes policiais.

A não apreensão dos isqueiros que o réu portava não é suficiente para convencer que os policiais mentiram sobre a revista e localização de drogas com ele, na verdade a apreensão destes objetos era irrelevante por não ter relação com o tráfico de entorpecentes.

A corroborar a fala dos agentes da lei, a genitora do acusado asseverou que os policiais vieram dos fundos do muro com a droga encontrada e que na casa moravam

ela, a filha de 16 anos e o marido, e ninguém usa drogas. Portanto, certamente não eram os proprietários das porções de maconha encontradas. O fato de as drogas que estavam nos fundos da casa terem embalagem idênticas às porções que estavam com réu é indicativo de que tudo lhe pertencia.

Em que pese o réu estivesse trazendo na via pública apenas cinco porções de maconha e tenha dito ser mero usuário isso não impede que seja traficante. Mesmo a mais inocente das criaturas sabe que traficantes do final da cadeia delitiva levam consigo, de propósito, uma quantia não muito grande de narcóticos, justamente para fingirem à Polícia que são meros usuários – sujeitos a sanções penais ridículas – e não traficantes, que infernizam a vida não só dos infelizes viciados, mas de todas as pessoas próximas a eles: pais, mães, irmãos, parentes, amigos, etc.

Com a devida vênia ao entendimento da combativa Defensora, o réu sequer alegou em seu interrogatório ser usuário ou que as drogas eram para seu consumo pessoal. Na verdade, ele negou a propriedade de todas as porções apreendidas. Ainda que não fosse, o fato de o requerido ser usuário de entorpecentes não afasta o crime de tráfico de drogas. Isso porque foi apreendida relevante quantidade de entorpecentes (mais de 100g de maconha) e a genitora do réu disse que na época ele não trabalhava e não lhe dava dinheiro. Assim, não é crível que tivesse condições financeiras de comprar toda a droga apreendida apenas para seu consumo pessoal.

Sabe-se que, não raro, usuários de drogas acabam atraídos para o comércio nefando até como uma forma de subsidiar o vício. Porém, a desclassificação pretendida só é admitida quando se comprova que a posse do entorpecente se destina, exclusivamente, a consumo próprio, situação que não se verifica neste caso concreto. As evidências de que existiram atos ilícitos de posse para mercancia não podem ceder lugar para a posse de drogas para uso próprio.

Portanto, não obstante os argumentos deduzidos pela Defesa, as evidências de que existiram atos ilícitos não podem ceder lugar para a posse de substância entorpecente para uso próprio. O réu pode até ser usuário de drogas, mas deve prevalecer, para fins penais, no caso em tela, a conduta descrita no tipo que define o crime de tráfico, mais gravosa perante a sociedade, por não ter sido provado que as drogas eram destinadas exclusivamente ao uso próprio. Assim, não é possível desclassificar a conduta para o porte de drogas para o uso próprio, como pretendido.

Por fim, destaco que o réu já foi condenado várias vezes por tráfico de drogas quando menor de idade e tem uma condenação definitiva por este tipo de crime quando maior de idade. A própria mãe admitiu que Antônio Carlos já trafica desde os seus 13 anos de idade. Apesar do passado do agente não constituir prova, pode reforçar convicções quando evidencia que o ato incriminado é simples rotina na vida do acusado (RT 564/393).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do acusado qualquer dirimente:

A culpabilidade é normal para a espécie. O réu ostenta maus antecedentes por condenação anterior por tráfico de drogas, a qual transitou em julgado pouco depois do fato tratado nestes autos. Não há informação acerca de sua personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo.

Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase há a atenuante da menoridade relativa, já que era menor de 21 anos quando do crime. Reconheço também a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, pois o isolamento e as restrições impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que

levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Também há notícias de que policiais tem ficado doentes por causa do Coronavírus, de modo que não é absurdo concluir que essa pandemia pode afetar a fiscalização de crimes como o tráfico. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública” (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, “se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Portanto, compenso uma agravante pela atenuante e mantenho a pena provisoriamente no mesmo patamar.

Na terceira fase não há causas de aumento e de diminuição. É impossível aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em virtude da condenação definitiva por tráfico de drogas, a indicar seu envolvimento com a criminalidade e que o acusado fazia do tráfico o meio de vida desde longa data, o que, aliás, foi confirmado pela própria genitora em Juízo. Assim, atinge a pena o montante final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada no interrogatório, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi da condenação anterior por tráfico, do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico.

Justifico a fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena também pelo tráfico de grande quantia de drogas, a indicar um envolvimento reiterado com este tipo de crime, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Carta Magna.

Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. Orig. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.09).

Ressalto que o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Nesse aspecto, acerca da necessidade do regime mais grave para o tráfico de drogas, cito o voto do eminente Desembargador Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0004588-12.2016.8.26.0189, julgado em 21/09/2017:

"Esse desgraçado vício da cocaína chegou em nosso país e, principalmente, nessa cidade de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem logradouros públicos, que foram praticamente tomados por viciados. É bom lembrar que o usuário de cocaína quando não tem dinheiro para adquirir a cocaína pura, que é em forma de pó, passa a se utilizar de uma forma inventada nos Estados Unidos, mais, precisamente na cidade de Nova York, no início dos anos 1970, denominada crack, aliás muito mais potente no sentido de fazer com que apenas com uma aspiração da fumaça tóxica (coloca-se a pedra em um pequeno cachimbo, conhecido como "marica", geralmente de vidro, esquentando-se embaixo com uma chama de isqueiro ou fósforo, e a pessoa suga a fumaça que desprende da pedra de "crack") já se torna dependente desta desgraça que foi inventada por indivíduos alheios a qualquer sentimento de piedade e que tinham somente interesse em ganhar dinheiro. Ora, uma pessoa que transforma seu semelhante num morto vivo, ou seja, um verdadeiro zumbi, como os que se vê na mídia, principalmente televisiva, indivíduos convivendo juntos na maior sujeira e promiscuidade, sendo que os locais onde essas pobres almas habitam, tem que ser constantemente lavado, com jatos de água e detergentes, pela Prefeitura Municipal, a fim de remover o fedor que exala do chão devido às secreções e excrementos que essas pessoas deixam naqueles locais. Tudo o que disse acima, e que é do conhecimento de todos, acontece por apenas uma razão, devido à ação de pessoas destituídas de qualquer sentimento de amor ao próximo, como é o caso do traficante e, nesses autos, do acusado. Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que, com sua atividade de traficantes, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas. O direito, como é cediço, é uma ciência mutável, ou seja, ele tem que acompanhar a evolução humana, e se adaptar às suas necessidades que mudam a cada época do desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, como uma das finalidades da pena é intimidar um possível criminoso, é mais do que óbvio que um crime como o tráfico de drogas, que, sem falar nos males causados à pessoa humana, abre as portas para inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, homicídios, prostituição etc.; não pode receber um tratamento menos gravoso do que um delito de menor potencial ofensivo. Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser preso não há outro regime, senão o inicial fechado, como forma de contraprestação do Estado à sua conduta. Fixar-se um regime mais benéfico do que o inicial fechado, seria conceder-se uma benesse ao réu, a qual ele não é merecedor".

No mais, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade.

Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Antônio Carlos dos Santos Filho, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita porque se trata de réu pobre. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que não houve pedido de prisão pelo Ministério Público e por regra trazida pela Lei "Anticrime" não é mais possível ao Juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Oficie-se ao processo 1502999-07.2020.8.26.0047, da 2ª Vara Criminal e da Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, informando o atual endereço de Antônio e que foi decretada sua prisão preventiva nos autos 1502886-53.2020.8.26.0047.

Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Expeça-se mandado de prisão em regime fechado em desfavor do réu e com o seu cumprimento, extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Expeça-se certidão de honorários à Defensora dativa que atuou no processo; 5) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 6) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 7) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 8) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 9) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 10) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 11) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 12) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

Assis, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA